

1501638-06.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Luciana Castello Chafick Miguel

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... as circunstâncias em que os crimes de tráfico e porte de arma de fogo com numeração suprimida foram praticados evidenciam que o réu se dedica a atividades criminosas, o que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Em razão do concurso material de crimes, as penas devem ser aplicadas cumulativamente. O regime inicial de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

1501638-06.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501638-06.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDERVAN SANTOS OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Castello Chafick Miguel

Vistos.

EDERVAN SANTOS OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 16, §1º, inciso IV da Lei nº 10.826/03, ambos os crimes combinados na forma do artigo 69 do Código Penal, porque em 8 de maio de 2021, por volta de 18 horas, na esquina da Rua Brigadeiro Faria Lima com a Avenida Hugo Maia, bairro Rádio Clube, em Santos, foi surpreendido ao trazer consigo, 208 (duzentos e oito) porções de maconha, pesando 1.070g (um mil e setenta gramas), e 48 (quarenta e oito) pedras de crack (derivado da cocaína), pesando 30 (trinta gramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, bem como nessa ocasião foi encontrada uma arma (revólver calibre 38) com identificação suprimida, contendo 03 (três) munições intactas, sem autorizações e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

A Audiência de Custódia foi dispensada em razão da Recomendação nº 62 do Conselho

Nacional de Justiça diante da pandemia global do Covid-19 e, apresentados os argumentos do Ministério Público (fls. 26/29) e da Defesa (fls. 34/39), a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 40/42).

Laudo químico-toxicológico (fls. 82/84) e Laudo pericial da arma (fls. 108/112, 123/127).

Regularmente notificado (fls. 86), o réu apresentou defesa previa (fls. 88/100). A despeito dos argumentos invocados, a denúncia foi recebida em 11 de junho de 2021 (fls. 113/117).

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, oportunidade em que a denúncia foi aditada para corrigir o erro material na quantidade de porções e quilogramas, assim como postular pela regra prevista no artigo 69 do Código Penal, como crime de tráfico e de porte de arma de fogo com numeração suprimida, em concurso material (fls. 187/189).

Em audiência de continuação foram ouvidas as testemunhas faltantes e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, os debates foram convertidos em memoriais, onde as partes sustentaram seus respectivos pontos de vista.

O ilustre representante do Ministério Público pediu a procedência do pedido contido na denúncia, com a condenação do réu, eis que os fatos descritos na exordial restaram devidamente comprovados. No que tange à pena a ser aplicada, observando-se os critérios judiciais existentes no artigo 42 da Lei 11.343/06, a pena base quanto ao crime de tráfico deve ser fixada acima do mínimo legal, haja vista que o réu trazia consigo expressiva quantidade de drogas de mais de uma espécie, embalada individualmente, pronta para a distribuição a terceiros, quais sejam: 208 (duzentas e oito) porções de maconha, pesando 1070 (mil e setenta) gramas, e 48 (quarenta e oito) pedras de crack, pesando 30 (trinta) gramas. O réu possui condenação definitiva anterior pela prática do crime de roubo, é reincidente, razão pela qual incide em seu desfavor a respectiva agravante preponderante. Além desses motivos, as circunstâncias em que os crimes de tráfico e porte de arma de fogo com numeração suprimida foram praticados evidenciam que o réu se dedica a atividades criminosas, o que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Em razão do concurso material de crimes, as penas devem ser aplicadas cumulativamente. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado em razão do montante de pena a ser aplicado e das circunstâncias judiciais que não são favoráveis ao réu, que é, ademais, reincidente, conforme ponderado. Por fim, tendo o acusado sido preso em flagrante delito e respondido ao presente processo preso, coerente – e de acordo com o mais abalizado entendimento jurisprudencial – seja mantido no cárcere após sua condenação, razão pela qual requeira seja, vez mais, indeferido seu pleito liberatório (fls. 252/270).

A Defesa, por sua vez, pediu a improcedência da ação penal, isso porque o conjunto de provas colhidos nos autos não comprova o crime que é imputado ao acusado. A narrativa do acusado é corroborada pelas testemunhas Gabriela e Nelson, ambas foram capazes de afirmar a presença do acusado no estabelecimento, e assim sendo, o que carregava, isto é, celular e carteira (há harmonia entre essas e as demais provas, especialmente a oitiva da Delegada de Polícia). Em suma, entende pela absolvição do acusado, na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, da qual vigorará quando houver dúvida razoável da efetiva participação do acusado para com o crime.

É a síntese do relatório.
Fundamento e DECIDO.

Consta da denúncia que: "o denunciado caminhava com uma mochila nas costas de cor cinza, com detalhes nas cores preta e laranja, contendo as drogas acima e a referida arma na cintura.

No momento em que avistou a aproximação de uma viatura em patrulhamento de rotina, o denunciado empreendeu fuga e entrou em um beco, onde largou a mochila e voltou, ocasião em que foi abordado.

Na cintura do denunciado, foi apreendido o revólver calibre 38 com a numeração suprimida, contendo três munições intactas.

No referido beco onde o denunciado havia entrado, os policiais encontraram a mochila que ele havia dispensado, na qual foram apreendidas as drogas acima. O denunciado foi preso em flagrante." (fls. 60/63).

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02 e 06), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), pelos depoimentos prestados em sede de delegacia (fls. 10/11 e 14/15), pelos laudos periciais da droga e da arma apreendida (respectivamente, fls. 82/83 e 108/112), assim como pelas demais provas orais coligidas aos autos.

A autoria, por sua vez, é certa para sustentar um decreto condenatório.

Os policiais militares narraram a diligência com riqueza de detalhes.

O Policial Militar Wilian de Oliveira Dias, ouvido em juízo, informa que estava em patrulhamento quando visualizaram o acusado com uma mochila nas costas. Ele adentrou rapidamente em um beco, mas dele saiu sem a mochila. Abordado, estava com revólver em sua posse. Ele tentou se desvencilhar da abordagem e, no interior do beco, após varredura, encontraram a mochila cinza que ele levava com a quantidade da droga apreendida. Estava bem próximo do local da abordagem. Ele não era conhecido nos meios policiais. O local é conhecido como ponto de tráfico. No beco em que ele foi detido havia casas, um conjunto de habitação. Populares transitavam normalmente, mas ninguém se apresentou na ocorrência. Eles conseguiram ver a abordagem. Era o segurança da viatura, estavam em quatro policiais. Sérgio era o encarregado. Tudo foi muito rápido, pois local de risco para os policiais e não conseguiram arrolar qualquer testemunha. As pessoas observam, mas não querem se envolver temendo represálias. Era final de tarde, mas já estava escuro. Na Delegacia de Polícia chegaram duas mulheres, mas desconhece como chegaram. Eram parentes do acusado. Gabriela Bispo disse que era caixa do estabelecimento, mas não se recorda de ter um comércio nas adjacências. Embora neguem que o acusado estivesse com mochila, isso não foi o que presenciaram. Não agrediram o acusado. O beco vai até as palafitas, única saída. Pediram para a genitora pegar um documento na Delegacia porque era uma abordagem de rotina. O acusado tentou fugir, mas sem êxito. Questionado pela Defesa, disse não ter conhecimento de que a Delegada havia lavrado flagrante apenas quanto ao porte de arma, pois apresentaram o acusado com arma e com as drogas. O local onde ocorreu a abordagem era bem iluminado, porém, o beco era bem escuro. Esclareceu que o réu foi avistado na via principal e adentrou no beco e lá permaneceu por cerca de trinta segundos. Recordou que a distância do beco até as palafitas era um pouco mais que uma quadra e que recuperaram a mochila logo no começo do beco. Disse que não havia mais ninguém no beco e que não conhecia o acusado anteriormente, mas não sabe dizer se ele é conhecido dos meios policiais. O acusado não apresentou nenhuma versão quanto à posse das drogas e da arma de fogo. Pontuou que no momento em que a genitora do acusado compareceu junto à viatura, as drogas já se encontravam apreendidas e essa informação não foi repassada pois ali é um local de risco para os policiais, motivo pelo qual tinham que sair o mais brevemente possível.

O Policial Militar Sérgio André da Silva Júnior, ouvido em juízo, narrou que o local é conhecido como ponto de tráfico e de confronto com policiais, quando visualizaram o acusado, que trazia uma mochila cinza com detalhes laranja, chamando

bastante atenção. Ao avistar a viatura, ele adentrou no beco e saiu poucos segundos depois, sem a mochila. Ele tentou empreender fuga, mas seu chinelo quebrou, o que dificultou. Abordado, em busca pessoal, ele estava com uma arma de fogo na sua cintura, revólver 38 com numeração suprimida e municiada, assim como um celular. No início do beco, por ser muito escuro, não avançaram, mas visualizaram a mochila logo na entrada. Tudo foi muito rápido em razão do risco à equipe. Na saída pediram que a mãe dele levasse documento para levar um documento pessoal até a Delegacia de Polícia. Não sabia onde morava, mas acredita que morasse próximo pela presença da familiares. Não sabiam quanto tempo demoraria e o local trazia risco. A sua equipe não conhecia o acusado, mas em pesquisas descobriram que ele tinha diversas passagens criminais. A viatura do BAEP é uma Blazer de cor cinza, mas discreta. Acredita que ele tenha sido surpreendido quando já estavam muito próximo dele. Na rua havia transeuntes, assim como compareceram parentes no local e que foram na Delegacia de Polícia. Toda abordagem no local traz risco aos moradores, pois o tráfico é armado no local. Testemunhas tem receio de retaliação e, por isso, se afastam no momento da abordagem. Não sabe dizer se tem um comércio próximo do local. Passam com certa frequência, mas são momentos tensos que não se recorda de ter passado por um bar. Não se recorda do beco de outras ocorrências. Não entraram até o final do beco, apenas no começo aproveitando a iluminação da rua principal. Temeram algum confronto com a criminalidade armada. É muito comum, com diversos calibres, até mesmo armas longas. O ponto de tráfico é volante, ficam próximo ao beco. A Faria Lima é uma via movimentada e iluminada, mas muito perigosa, composta de diversos becos e alguns deles muito perigosos. Trabalha na área operacional da Polícia Militar, não sabe se houve algum confronto recente no local. Era apenas a sua viatura no local, não se recordando se outras viaturas apareceram no local posteriormente. Reafirmou que solicitou aos parentes que levassem o documento do réu à Delegacia.

Com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, "os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

As declarações dos policiais devem ser acolhidas sem ressalvas, pois, além de harmônicas entre si e com as demais provas existentes nos autos, não há indícios de que faltaram com a verdade em seus depoimentos ou que tivessem qualquer espécie de interesse na condenação do réu.

Acrescente-se que a palavra do policial é digna de confiabilidade. Afinal, não faz sentido o Estado investir alguém em suas funções para depois desacreditá-lo, notadamente quando inexistia prévia animosidade capaz de levar a uma falsa imputação como sustentada pela defesa.

Nesse sentido: "PROVA. Depoimento de Policial. Valor. A palavra do Miliciano não pode ser considerada indigna de fé, só porque ele ostenta esta qualidade, pois seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu agente, e, ao depois, quando este presta conta de suas diligências, taxá-lo de suspeito." (RJDTACRIM VOLUME 25JANEIRO/MARÇO/1995 PÁGINA:241 RELATORES: - XAVIER DE AQUINO)

Ainda, a testemunha arrolada pela defesa, Dra. Claudia Santana Barazal, Delegada de Polícia, disse que o auto de prisão em flagrante ocorreu em razão do porte de arma de fogo com numeração suprimida, mas a hipótese do tráfico não foi descartada, sendo relatada na ocorrência, pois a droga encontrada não estava em seu poder. A arma estava em poder dele, não deixando dúvidas acerca da autoria. A mochila estava em um beco e, embora os policiais tenham afirmado que viram o acusado na posse

dela, restaram dúvidas a respeito pela presença das testemunhas. Acredita que nenhuma outra diligência foi realizada antes do relatório final lavrado no dia seguintes, pois a ocorrência ocorreu durante o final de semana. Acredita que tenha feito outras ocorrências com os policiais e desconhece qualquer fato que os desabone. O local é conhecido pela grande incidência criminal, em especial o tráfico e realmente costuma haver troca de tiros no local da ocorrência.

Gabriela Bispo Oliveira, como testemunha, disse que compareceu a delegacia assim que terminou seu expediente no bar, onde aconteceu a prisão e a abordagem do réu pelos Policiais. Ele esteve no bar e pediu um pedaço de bolo com café e, ao sair do local, os policiais o abordaram e o encostaram na grade da frente do estabelecimento, realizando revista pessoal. Os policiais perguntavam o que o réu tinha em sua posse. Ele estava com a carteira e celular, pois ele pagou com dinheiro que tirou da carteira. Os policiais levaram o réu para frente de uma residência ao lado do bar. Na revista pessoal ele não estava com mochila ou arma, nem mesmo quando entrou no estabelecimento. Negou existir um beco nas proximidades que dê acesso à Maré, que fica mais para trás do local dos fatos. Atrás do bar existem diversas residências da CDHU, mas não casas em palafitas. Atrás do bar não existe beco que saia na "Maré". O bar é bem movimentado e conhecido, fica de frente para a Avenida Hugo Maia, avenida com bastante movimento. Trabalha no bar há 4 meses e ficaram fechados por um tempo em razão da Pandemia, mas o estabelecimento funciona há aproximadamente 03 anos. No momento em que os policiais abordaram o réu, levantaram sua camisa e ele não estava com nada em sua cintura. Não daria tempo do réu esconder a mochila, pois assim que saiu do bar, já foi abordado pelos policiais. Seu horário de trabalho no estabelecimento é das 12h às 22h e conhece o réu do bar, pois é frequentador. No bar as pessoas comentam sobre quem é envolvido com a criminalidade e nunca ouviu nenhum comentário em relação ao réu. Desconhecia que o réu possui uma condenação pelo crime de roubo. Após seu horário de trabalho foi até a Delegacia de Uber, junto a uma outra testemunha que não recorda o nome. O bar fica longe da Delegacia, mas não se recorda qual o valor da corrida. A mãe do "Edi" pagou a corrida de Uber. Colocou-se à disposição da mãe do acusado para depor, pois tinha presenciado os fatos. Conversou com a outra testemunha que não se recorda o nome sobre o ocorrido, assim como várias pessoas também presenciaram os fatos, mas, talvez por medo de se envolver, não prestaram depoimento. Na verdade conversou com o irmão do réu e não com a mãe, que foi atrás do carro da polícia, após o réu ser levado. Conhece o irmão do réu pelo apelido de "Nego", também do bar. O irmão do réu contatou um Uber que já a esperava na porta do bar quando saiu do expediente, que ficou aguardando o término de seu depoimento e da outra testemunha na Delegacia de Polícia para levá-las para casa. A família do réu mora perto do bar, na mesma calçada, mas não em qual casa. Questionada se chegou a perder o réu de vista, respondeu que assim que o réu saiu do bar, aproximadamente um minuto depois, percebeu que os policiais o encostaram na grade. Já estava escurecendo, mas não se recorda o horário, mas acredita que era entre 18 e 19hs, com o bar já bem movimentado. Enquanto esteve no bar consumindo, o réu não carregava mochila. Não conhece os policiais que realizaram a abordagem e nem ter presenciou outra abordagem parecida no estabelecimento, desconhecendo o motivo pelos quais os policiais o acusariam de cometer algo tão grave.

Ediwiges Helena Pereira, ouvida em juízo, testemunhou que foi para a delegacia de Uber, sozinha e por livre e espontânea vontade. Mora na mesma calçada do bar, aproximadamente uns 10 metros, umas três casas depois, onde reside há três anos. O bar funciona no local há bastante tempo. Desconhece algum beco atrás do bar que dê acesso à "Maré", pois não tem o costume de andar por ali. Raramente frequenta o bar, não possui relação íntima com o acusado ou familiares, apenas são conhecidos da vizinhança. No dia dos fatos, o réu foi até o bar para comprar bebidas e comida, pois os meninos tem esse costume, eles vendem salgadinhos. Na mão ele trazia apenas o celular e a carteira. Ouviu uma gritaria e viu a abordagem agressiva realizada pela polícia. Estava a aproximadamente 03 metros e viu os policiais agredindo o réu, chegaram até a bater sua cabeça no portão da sua residência. Ele foi abordado

quando saia do bar, sendo que só tinha o celular e a carteira nas mãos. A brutalidade da polícia chamou muito sua atenção. Confirmou ter ido à Delegacia de Uber, mas retornou para casa junto com a menina do bar e dividiram o valor da corrida. Não se recorda o valor da corrida até o 3º DP da Ponta da Praia, mas realmente não foi um valor barato. Colocou-se à disposição da família para ajudar e que foi até ao DP tarde da noite, porque demorou para chegar a informação de onde o réu estava. Não presenciou tão somente o final da abordagem, momento em que os policiais puxaram o réu e passaram a agredi-lo. Confirmou ter dividido a corrida do Uber na volta do Delegacia, com a menina do bar. Não tem amizade com ela. É vizinha de "Van" há aproximadamente 03 anos, mas não possui contato próximo com ele ou seus familiares. Manteve contato com a namorada do réu, que passou a informação de seu paradeiro após a prisão. Não se recordou do nome dela. A mãe e o irmão do réu foram até o local após a abordagem. Recorda que o irmão do réu tem o apelido de "Baixada". Desconhece qualquer iniciativa dos familiares quanto à abordagem agressiva dos policiais e também não procurou a polícia para formalizar nenhuma reclamação. Acredita que essa reclamação deve ser de iniciativa conjunta, partindo dos familiares do réu. Várias pessoas presenciaram as agressões ao réu, não sabendo dizer porque outras pessoas não procuraram a polícia para testemunharem em favor dele. Não soube informar o nome do Bar, reafirmando que fica três casa à frente da sua. Confirmou que o bar compartilhado na tela da teleaudiência é realmente o local dos fatos. Não soube dizer para onde o beco ao lado do bar leva, pois nunca anda para esses lados. Esclareceu que na verdade, diferentemente da foto, agora existe um portão de acesso ao beco. Disse ainda acreditar que os familiares tiveram conhecimento da abordagem rapidamente, porque alguém deve ter avisado.

Nelson Coelho Vieira, ouvida em juízo, disse que estava em um barzinho comprando algumas coisas, oportunidade em que viu o réu se levantar do bar e caminhando em direção da sua casa. A viatura se aproximou e realizou a abordagem. Estava a aproximadamente 25 metros de distância, acompanhando tudo que faziam. Viu e ouviu tudo. No momento em que os policiais o pararam ele não carregava nada nas mãos. Posteriormente, a mãe e o irmão do réu apareceram e conversaram com os policiais. Reafirmou que o réu não tinha nada nas mãos. Disse que estava na calçada, em frente ao bar, comprando cigarros, no momento da abordagem. Permaneceu observando o que estava acontecendo por curiosidade. Esclareceu que o réu estava em outro bar, do mesmo lado da calçada, próximo, onde comprava os cigarros. Não sabe se o réu foi até um beco nas proximidades, acredita que ele foi comprar alguma comida, pois viu uma menina se aproximar com um marmite, mas ela retornou. No momento em que passou pelo bar onde estava o réu, nada aconteceu. A abordagem pelos policiais foi posterior. Em razão de problemas com a conexão, sua oitiva foi redesignada e, novamente, reafirmou que foi comprar cigarros quando viu o momento em que o réu saiu do bar e foi abordado pelos policiais, que ficaram conversando com ele. Em seguida, apareceram seus familiares. Em nenhum momento viu o réu carregando alguma coisa. Acredita que estava aguardando alguma comida que havia comprado no bar. Presenciou toda a abordagem policial a aproximadamente 20 metros de distância. O bar já existe a bastante tempo e fica bem movimentado em razão dos lanches. Conhece a menina que trabalha no bar apenas de vista, não é frequentador do local, com compras esporádicas. Havia apenas uma viatura com quatro policiais durante a abordagem, que ocorreu após às 18hs. Não se lembra como era a viatura. Prestou depoimento por livre e espontânea vontade. Conhece alguns policiais militares. Não teve conhecimento de alguma operação que resultou na apreensão de drogas no Batalhão do BAEP. A abordagem durou aproximadamente 25 minutos, foi uma abordagem normal e os policiais agiram com educação. Minutos depois, os familiares do réu apareceram no local com o documento de identidade dele e conversaram. Não sabe o motivo do réu ter sido conduzido à Delegacia, destacando que a mãe do réu, durante a conversa com os policiais, ficou bastante exaltada. Ressaltou que não sabe por qual motivo colocaram o réu na viatura, mas no momento em que revistavam o réu, nada encontraram. Não dava para escutar o que os policiais e o réu falavam durante a abordagem. Apenas se recordou ter ouvido o réu mencionar que foi pegar algo para comer, quando aumentou o tom da voz. Saiu do bar onde o réu estava e foi para o

outro estabelecimento mais à frente para comprar cigarros. No momento em que aguardava o cigarro, surgiu a viatura policial e realizou a abordagem. Outras pessoas presenciaram a abordagem, mas não sabe dizer quais. Realizava um serviço na casa do Sr. Cláudio e saiu para comprar cigarros. Conhece o réu apenas de vista e que sua mãe o procurou pedindo para que prestasse depoimento. Ofereceu-se para acompanhá-la na Delegacia, mas ela disse que não precisava. Ela anotou seu telefone e depois o procurou para que testemunhasse. Foi até o bar em que o acusado estava para comprar cigarros, mas como não tinha, foi até outro. O réu já estava no local. Posteriormente, visualizou o momento em que o réu saiu do bar e foi abordado pelos policiais. Não sabe dizer se o réu se ausentou do local por algum momento, enquanto aguardava o lanche, ressaltando que foi muito rápido. Não sabe dizer quais motivos os policiais teriam para imputar acusação falsa ao réu, asseverando que não ouviu a conversa que ocorreu durante a abordagem ao réu. Respondeu que o bar onde o réu estava fica na Avenida Hugo Maia, possui umas grades na frente e uma mesa de sinuca nos fundos, atrás do balcão. Esclareceu que não mora nas proximidades, apenas prestava serviços no local e que não conhece a família dele, apenas o viu uma vez passeando com a filha. A mãe e o irmão conheceu apenas no dias em que os fatos ocorreram.

Jovita Maria da Silva Jesus explicou que no dia dos fatos retornava da Igreja e estava passando pela rua no momento em que a polícia abordou o réu e viu que ele nada tinha em suas mãos. O réu estava nas proximidades de um bar perto do canal. Mora um pouco mais acima do local e que onde abordaram o réu não havia nenhum beco, nem portão. Desconhece qualquer passagem para a "Maré" existente na viela atrás do bar. Vinha passando quando viu a abordagem policial, sendo que o réu não estava com nada nas mãos. Não ficou comentando sobre isso com os moradores locais. Mora no Caminho São José, nº 05 e a abordagem do réu foi em frente ao bar, na rua do canal Hugo Maia. Não sabe do que está sendo acusado e conhece "Van", pois ele mora ali por perto. Não mora muito longe do local da abordagem, mas não sabe precisar a distância. Forneceu seu contato para a mãe do réu, Silvana, que conhece da Igreja. No momento da abordagem a mãe do réu não se estava no local. Ela estava operada e apenas foi ao local depois de avisada. Já havia ido para sua casa. No dia seguinte procurou a mãe e contou que presenciou o momento da prisão. A mãe do réu comparece esporadicamente na Igreja. A mãe do réu mora próximo do local da prisão. Questionada sobre o acesso ao Caminho São José por meio de vielas existentes no local, em especial sobre uma onde existe um bar com mesas de sinuca, disse que o acesso ao Caminho São José se dá pela "Pista" e que não existem corredores ou becos de acesso, pois são ruas onde há comércios.

O réu Edervan Santos Oliveira, em seu interrogatório, narra que saía do bar após comer um bolo e tomar um café. Veio da praça da Hugo Maia e ali parou antes de agendar seu corte de cabelo. Não estava com drogas ou arma. Em seguida, sua mãe e sua mulher compareceram no local, ocasião em que disse para a mãe ir pegar seu RG que estava na gaveta do armário. Sua casa fica aproximadamente 5 casas depois do local em que foi abordado. Os policiais ficaram fazendo perguntas e dizendo para que contasse a casa onde estavam escondidas drogas para poderem liberá-lo, mas não tinha conhecimento sobre isso. Pegaram o seu celular e insistiram para que relatasse a casa onde havia drogas, ocasião em que reafirmou desconhecer. Nesse momento, foi agredido com uma joelhada. A sua mãe saía de casa e viu a agressão, e gritou com os policiais. Também apanhou dos policiais militares em uma rua sem saída ao lado do 1º DP, após negar novamente conhecimento sobre a existência de uma casa onde havia drogas. A sua mãe e namorada presenciaram o momento em que estava com o pano na boca, próximo ao 1º DP. Recebeu choque dos policiais e foi apresentado na Delegacia com vários hematomas. Esclareceu que saiu do bar e ia marcar de cortar o cabelo no salão que fica bem ao lado, mas a viatura o abordou e perguntaram se tinha passagem. Não se esquivou da resposta afirmativa. E, apenas por isso, foi "enquadrado" pelos policiais. Reafirmou que saiu da pracinha na Avenida Hugo Maia e foi direto para o bar. Não entrou em qualquer beco. Após sair do bar foi na direção do salão de cabeleireiro para marcar horário. Antes de ser

preso estava trabalhando em um lava rápido na Avenida do Canal, onde fica o Krill, mas no dia dos fatos, um sábado, estava de folga. Não é registrado e recebe cerca de R\$ 1.200,00 por mês. Conhece a moça que trabalha no bar, era nova. Fazia um mês e meio que trabalhava lá. Os policiais colocaram um pano em sua boca e o agrediram atrás do DP, ocasião em que sua mãe e mulher presenciaram tais agressões e ficaram abaladas. Confirmou ter levado um choque na cintura, joelhadas, além dos policiais terem colocado um pano na sua boca. Chegou na delegacia com vários hematomas.

De acordo com as fotos ilustradas no BOPM, a descrição da mochila se coaduna, perfeitamente, com aquela narrada pelas testemunhas que estava nas costas do acusado, uma mochila cinza, com detalhes na cor laranja, ganhando destaque (fls. 174).

Os policiais militares foram firmes no sentido de que o acusado adentrou e saiu rapidamente do beco sem a mochila, dando a certeza de que era a mesma pessoa, seja pela brevidade da abordagem e surpresa, seja porque não havia outra pessoa no início do beco, seja porque ele tentou empreender fuga que foi frustrada pelo rompimento do seu chinelo.

Ainda, houve flagrante delito com relação ao porte de arma de fogo, como a Delegada de Polícia falou em audiência, testemunha de defesa, sem afastar a hipótese da sua autoria quanto ao tráfico, sendo que nada mencionou acerca de lesões corporais do réu decorrente de violência policial.

O exame de corpo de delito foi requisitado pela autoridade policial às fls. 17, sendo que a defesa sequer insistiu na cobrança do laudo para provar a sua alegação de tortura, explorando a dúvida em seu favor. Impressiona o número de testemunhas que olhavam detidamente para o percurso do réu que antecedeu a abordagem e que não se intimidaram de permanecer no local durante a abordagem, em um local marcado pelo forte confronto com traficantes.

Ainda, a genitora e namorada estiveram na Delegacia e nenhuma providência solicitaram da autoridade policial acerca das agressões, o que torna muito duvidosa a prova da violência, notadamente quando empregaram esforços para o comparecimento de testemunhas para contestar a situação flagrante e nada fizeram constar neste sentido.

A prova produzida pela defesa foi por demais contraditória, merecendo destaque a palavra da testemunha Nelson, que afirmou ter presenciado a abordagem e negou qualquer ato de violência contra o acusado, que se sujeitou a uma abordagem rotineira, oportunidade em que os policiais conversaram com o réu e seus familiares presentes.

É certo que ele também nega que o acusado estivesse com algo em suas mãos no momento da abordagem, mas isso é ponto incontroverso: a mochila foi abandonada momentos antes e a arma estava na sua cintura.

Gabriela disse que o bar e a rua eram bem movimentadas na oportunidade e a escolha aleatória do réu não parece crível, assim como disse que depois de ser prensado contra a grade do bar, foi abordado na residência ao lado, sem qualquer episódio de agressão, ao passo que a outra testemunha de defesa, Ediwirges, disse que o acusado foi violentamente agredido e chegaram a bater sua cabeça no portão da sua casa, que fica umas três casas depois do bar.

Importante destacar a contradição acerca de quem acompanhou e financiou a ida de ambas até a Delegacia de Polícia, pois a primeira afirma que ambas foram juntas e que a família do acusado financiou a corrida, ao passo que a segunda disse que custeou sua ida e dividiu o valor da volta com a primeira.

O local é conhecido ponto de confronto entre policiais e traficantes e, diferente do que afirmado pelas testemunhas de defesa, o local tem dois becos, um de cada lado do bar e, de acordo com o que foi falado por uma das testemunhas, após a atualização do Google Maps, está com um portão verde em um deles, mas que permanece aberto.

Veja que o acusado estava muito próximo de qualquer um dos dois e que os policiais foram firmes no sentido de que a mochila estava logo na entrada. Como já dito, num horário de pico, a escolha aleatória de alguém antes do encontro da mochila não apreça razoável.

Por outro ângulo, conforme linha vermelha por mim registrada, observe que existe passagem pelos dois becos e que levam ao Caminho São José, onde reside uma das testemunhas de defesa e amiga da igreja da genitora, e na parte inferior esquerda é possível ver a maré e casas de palafitas, contrariando a versão das testemunhas.

Vide link: <https://www.google.com/maps/@-23.9441718,-46.3839356,157m/data=!3m1!1e3>

Já as testemunhas Edwirges e Gabriela presenciaram apenas parte da abordagem, a primeira disse que ouviu gritaria e aí percebeu a abordagem violenta, ao passo que a segunda disse que, depois de um minuto que o acusado deixou o bar, percebeu que estava sendo pressionado contra as grades do bar e revistado, sem qualquer episódio de violência, mas insistiram que o acusado nada tinha de ilícito em sua posse no momento da abordagem.

Não é demais lembrar que Gabriela ainda disse que conhece "Edi" há um pouco mais de um mês, conhece seu irmão "Nego" e sua genitora, família responsável por custear sua corrida até a Delegacia de Polícia após seu expediente, acompanhada por Edwirges, que afirmou que foi por meios próprios e dividiu com Gabriela a despesa da corrida no retorno para casa.

Ainda deve ser destacado que a testemunha Nelson disse que viu o acusado na frente do bar ao deixar o local e que devia estar aguardando algo ser preparado, já que a moça um "marmitex" até ele, ao passo que Gabriela disse que ele entrou e ali fez a sua refeição.

A testemunha de defesa Jovita, em relato confuso, disse ter visto o momento em que o réu foi abordado pelos policiais e que este não estava com nada em seu poder, porém, afirmou que logo em seguida, foi embora para sua casa, não permanecendo no local até o final. Nada mencionou quanto às supostas agressões.

De fato, os relatos apresentados pelas testemunhas de Defesa não descartam, em hipótese alguma, a possibilidade do réu ter dispensado a mochila com drogas, conforme a narrativa dos milicianos. Isto porque, conforme seu próprio relato no interrogatório, estava na pracinha da Av. Hugo Maia antes de ir até o bar, onde teria ocorrido a abordagem.

Nenhuma das testemunhas de defesa esteve com o réu ou o avistou instantes antes da abordagem. Somente a testemunha Nelson relatou ter visto o réu no bar, porém, visualizou a abordagem quando estava em outro estabelecimento comercial, aproximadamente com uns 25 metros de distância e não afasta a possibilidade do réu ter dispensado a mochila com as drogas antes de adentrar ao bar ou após ter saído do bar, mas antes de ser abordado.

Nesta senda, diante do conjunto probatório formado, a prova oral produzida pelo réu em Juízo não é capaz de abalar a credibilidade do depoimento dos policiais militares, notadamente quando o depoimento contraditório das testemunhas de defesa

sinaliza que faltaram com a verdade em juízo com a intenção de favorecer o acusado e eximi-lo de responsabilidade criminal, o que merece ser apurado em ação penal própria pelo crime de falso testemunho com relação a Edwirges e Gabriela.

Com efeito, embora o réu tenha negado categoricamente em Juízo o seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes, não basta para invalidar o conteúdo incriminador o simples protesto de inocência, já que diante de tamanha divergência na dinâmica dos fatos, deveria apresentar elementos a darem sustentação às suas alegações, pois "o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF; 1ª Turma; H.C. nº 74608-0/SP; Rel. Min. Celso de Mello; DJU 11/4/97).

Se os policiais quisessem faltar com a verdade, sustentariam que o acusado não estava portando apenas a arma de fogo, estava com a mochila nas suas costas e com ela foi abordada, mas foram firmes e uníssonos na versão apresentada acerca da sua tentativa de esconder a mochila ou deixá-la naquele ponto para alguém, que não tinham dúvidas que ele foi a pessoa que entrou no beco e dele saiu sem a mochila.

Ainda, importante ressaltar que o acusado empreendeu fuga portando a arma de fogo ao notar a presença da aproximação da polícia, frustrada pelo rompimento de seu chinelo, em local marcado, repito, pelo intenso confronto entre policiais e traficantes.

Com efeito, a palavra do réu ficou isolada no contexto probatório, notadamente diante da versão coesa e harmônica dos policiais militares, assim como nenhum elemento de prova permite afastar a usual credibilidade dada aos seus depoimentos, conforme anteriormente mencionado.

A quantidade e variedade de drogas não deixam dúvidas acerca da sua destinação ao comércio ilícito de entorpecentes, reforçada pelo porte de arma de fogo, uma constante naquela rua, dominada pelo tráfico armado e palco de diversos confrontos.

Neste diapasão, ao tratar da antiga legislação, "A COMPROVAÇÃO DA ELEMENTAR DO TIPO PREVISTO NO ARTIGO 16 - USO PRÓPRIO - NEM SEMPRE É DE FÁCIL CONSTATAÇÃO, PREVENDO A PRÓPRIA LEI, EM SEU ARTIGO 37, ALGUNS CRITÉRIOS LEGAIS. ASSIM, PARA EFEITO DE CARACTERIZAÇÃO DAS CONDUTAS CRIMINOSAS PREVISTAS NA LEI 6368/76, DEVERÃO SER ANALISADOS A NATUREZA E A QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA, O LOCAL E AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO CRIMINOSA, AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, BEM COMO A CONDUTA E OS ANTECEDENTES DO AGENTE. DEVE, IGUALMENTE, SER LEVADA EM CONTA PARA EFEITO DE TIPIFICAÇÃO DO DELITO A FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE". (Legislação Penal Especial - Moraes e Smanio - ed. Atlas, pág. 122).

Destarte, como consta na denúncia (fls. 60/63) e nos termos de depoimentos ocorridos na Delegacia de Polícia (fls. 10/11 e 14/15), confirmado pela narrativa dos policiais frente ao juízo, o réu carregava consigo uma mochila, que dentro havia diversas drogas e em sua cintura, quando foi revistado, uma arma, revólver calibre 38, com numeração suprimida e três munições intactas.

Assim apurado no laudo pericial químico-toxicológico (fls. 82/84), foi detectada tetraidrocanabinol no primeiro invólucro, de novecentos e setenta e oito gramas e cinco decigramas, aproximadamente. Assim como foi detectada a substância de cocaína no segundo lacre, que o réu os carregava consigo, em doze gramas e sete decigramas.

Assim sendo: "CARACTERIZA O DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE TRAZER CONSIGO, SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, MACONHA E CLORIDRATO DE COCAÍNA, EM DOSES UNITÁRIAS, DE PEQUENOS EMBRULHOS, EMBALAGEM USUAL DO VAREJO DAS

DROGAS". (TJRJ – Rel. Enéas Machado Cotta, RDTJRJ 23/288).

Ainda: "IDENTIFICANDO O FORNECEDOR DAS SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, EM PODER DE QUEM FOI APREENHIDA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA, PARTE JÁ DIVIDIDA EM DEZENAS DE PAPELOTES, PRONTOS PARA ENTREGA A CONSUMO, IMPÕE-SE A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO, SEM QUE SE POSSA, TODAVIA, RECONHECER ASSOCIAÇÃO COM COMPRADORES". (TJRJ – Rel. Paulo Gomes da Silva Filho – RDTJRJ 20/313).

A saúde pública é um bem tutelado no Direito Penal, sobretudo porque "são as drogas que perturbam, modificam qualitativamente a atividade mental, levando o indivíduo a ter percepções irreais." (Hygino de Carvalho Hécules, Medicina Legal: texto e atlas. 2. Ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2014, p. 416)

Assim, a apreensão de quantidade relevante de entorpecente não deixa dúvida de que o destino seria a entrega a consumo de terceiros, sendo imperioso, portanto, a reconhecimento da figura do tráfico de entorpecentes prescrita pelo artigo 33, da lei nº 11.343/06.

Não é plausível a hipótese de tráfico privilegiado uma vez que o réu não se encaixa em tais parâmetro elencados no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei de Drogas.

O laudo pericial não deixa dúvidas acerca do crime previsto no artigo 16, parágrafo primeiro, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, já que portava uma arma com numeração suprimida (fls. 108/112).

Assim como os demais crimes do Estatuto, o crime em tela visa proteger e tutelar pelo bem jurídico da segurança e da paz pública. Ainda: "Foi enquadrada no mesmo tipo penal, o artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, tanto a conduta daquele que "porta" quanto a daquele que "possui" arma de fogo que apresente numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. É irrelevante o fato de o agente ter sido ou não o responsável por empreender a supressão do número de série da arma de fogo, uma vez que a conduta "suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato" constitui crime autônomo, tipificado no inciso I, do parágrafo único, do artigo 16 da Lei 10.826/03, e não é desse delito que tratam os autos. Por se tratar de crime de mera conduta, "não requer o delito à ocorrência de nenhum efetivo prejuízo para a sociedade ou para qualquer pessoa, ao passo que, classificado como de perigo abstrato, a probabilidade de dano, como o mau uso da arma ou munição, é presumida pelo tipo penal". (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 7. Ed. São Paulo; Revista dos Tribunais, 2013, p. 48). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." APL 0025556-53.2013.8.24.0018. Órgão Julgador Segunda Câmara Criminal. Julgamento em 15 de março de 2016. Relator: Sérgio Rizelo.

Assim, demonstrada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes e porte de arma de fogo com numeração suprimida, passo a dosimetria da pena.

1. Crime de tráfico de entorpecentes:

Tendo em vista a normal intensidade da sua conduta, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, as circunstâncias e conseqüências do crime, a quantidade e variedade de droga, fixo a pena base em 05(cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, calculados no mínimo legal.

Em face de sua reincidência, agravo a pena na fração de um quinto, resultando em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa (devidamente certificada nas fls. 24/25).

2. Crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida:

Tendo em vista a normal intensidade da sua conduta, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito e as circunstâncias e conseqüências do crime, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no mínimo legal.

Em face de sua reincidência em um crime de roubo (fls. 24/25), agravo a pena na fração de um quinto, resultando em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Por força da regra prevista no artigo 69 do Código Penal, somo as penas ora aplicadas ao acusado Edervan Santos Oliveira, resultando na pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, assim como ao pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa.

Em razão do caráter equiparado a hediondo da conduta perpetrada e a reincidência, o regime de cumprimento da pena será o inicialmente fechado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu EDERVAN SANTOS OLIVEIRA à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, assim como ao pagamento de dias-multa, em regime fechado, e ao pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, calculados, unitariamente, no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, ambos os crimes combinados na forma do artigo 69 do Código Penal.

Extraia-se cópias dos depoimentos e desta sentença e encaminhe-se para a Delegacia de Polícia para a instauração de inquérito policial para apuração do crime de falso testemunho Com relação as testemunhas Gabriela e Edwirges.

A alteração levada a efeito no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, no tocante ao instituto da detração, é de duvidosa constitucionalidade, por aparente violação dos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88), do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF/88) e da isonomia (art. 5º, caput, CF/88).

O merecimento do condenado integra os requisitos para sua promoção de regime, sendo crucial à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugere uma interpretação mais superficial do novo § 2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, dependendo do preenchimento dos requisitos tanto objetivos quanto subjetivos.

A reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do Código Penal, de tal sorte que a fixação de regime inicial ainda deve considerar obrigatoriamente, além da pena aplicada, se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.

Em razão do exposto, o desconto da pena cumprida pelo acusado deverá ser mesmo apreciado pelo Juízo das Execuções Penais.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois ele permaneceu preso durante toda a instrução processual, devendo, pois, continuar recolhido após a prolação da sentença condenatória, já que, se antes mesmo do julgamento do mérito ele estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação, pois: "seria incongruente que o réu preso provisoriamente em virtude de medida cautelar viesse, ao depois de condenado, ser libertado ex-vi da Lei 5.941/73. Poder-se-ia, então, dizer que ficou preso pelo menos e foi posto em liberdade pelo mais" (RT 504/339).

Consoante já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça: “Inaplicável é a outorga do benefício a quem já se encontra preso, em flagrante ou preventivamente, por ocasião da sentença condenatória”. (RHC 177 – RJ – 5ª Cam. Do STJ, v.u., rel. M. Assis Toledo, DJU de 30.10.89.)

Após o trânsito em julgado:

1. Preencha-se o boletim individual, encaminhando-o ao Instituto de Identificação Criminal (art. 809 do CPP).
2. Comunique-se o deslinde do feito ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da Magna Carta de 1988.
3. Proceda-se o cálculo da pena de multa, que deverá ser recolhida em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Após, intime-se o réu para o seu pagamento dentro de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão, nos termos do art. 50 do CP.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, no montante de 100 (cem) UFESP's, com base no contido no art. 4º, § 9º, alínea “b”, da Lei nº. 11.608/2003, observando-se, se for o caso, o contido no art. 12 da Lei nº. 1.060/50.

Determino a incineração da substância entorpecente apreendida, mediante auto circunstanciado, nos termos do art. 32, § 1º, da Lei nº. 11.343/2006 e a perda da quantia apreendida em favor da União.

P.I.C.

Santos, 09 de fevereiro de 2022.

LUCIANA CASTELLO CHAFICK MIGUEL
Juíza de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA